

正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではないが、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、侵害の急迫性の要件を欠く結果、そのような侵害に対する反撃行為に正当防衛が認められることはない。
2. 憎悪や怒りの念を抱いて侵害者に対する反撃行為に及んだ場合には、防衛の意思を欠く結果、防衛のための行為と認められることはない。
3. 相手からの侵害が、それに先立つ自らの攻撃によって触発されたものである場合には、不正の行為により自ら侵害を招いたことになるから、相手からの侵害が急迫性を欠く結果、これに対する反撃行為に正当防衛が認められることはない。
4. 刑法第36条にいう「権利」には、生命、身体、自由のみならず名誉や財産といった個人的法益が含まれるので、自己の財産権への侵害に対して相手の身体の安全を侵害する反撃行為に及んでも正当防衛となり得る。
5. 正当防衛における「やむを得ずにした」とは、急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味し、反撃行為が防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、その反撃行為が正当防衛でなくなるものではない。

No.81	正当防衛	正答率
共通H25-13	正 解 2、3 (順不同)	94%

1 正しい

最決昭 52.7.21 (百選 I [第7版] 23 事件)。本記述では、単に予期された侵害を避けなかったといふにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、侵害の急迫性の要件を欠き、正当防衛が認められないのが問題となる。判例は、「刑法 36 条が正当防衛について侵害の急迫性を要件としているのは、予期された侵害を避けるべき義務を課する趣旨ではない」とした上で、「単に予期された侵害を避けなかったといふにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさないものと解するのが相当である。」として、正当防衛の成立を否定している。

2 誤っている

最判昭 46.11.16、最判昭 60.9.12。本記述では、憎悪や怒りの念を抱いて侵害者に対する反撃行為に及んだ場合には、防衛の意思を欠くとして、防衛行為とは認められないのが問題となる。判例は、「刑法 36 条の防衛行為は、防衛の意思をもつてなされることが必要であるが、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、ただちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない」とし (最判昭 46.11.16)、「急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、たとえ、同時に侵害者に対し憎悪や怒りの念を抱き攻撃的な意思に出たものであつても、その行為は防衛のための行為に当たると解するのが相当である」としている (最判昭 60.9.12)。

3 誤っている

最決平 20.5.20 (百選 I 26 事件)。本記述では、自らの攻撃に触発されて相手から侵害がなされた場合には、相手からの侵害が急迫性を欠くとして、相手の侵害に対する反撃行為に正当防衛が成立し得ないのが問題となる。判例は、「被告人は、A から攻撃されるに先立ち、A に対して暴行を加えているのであって、A の攻撃は、被告人の暴行に触発された、その直後における近接した場所での一連、一体の事態ということができ、被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえるから、A の攻撃が被告人の前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては、被告人の本件傷害行為は、被告人において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである。」として、一定の留保を付した上で、正当防衛の成立を否定している。そうすると、自らの攻撃に触発されて相手から侵害がなされた場合であっても、正当防衛が成立し得る場合があるといえる。

4 正しい

最判平 21.7.16 (重判平 21 刑法 1 事件)。本記述では、36 条 1 項の「権利」には、名誉・財産といった個人的法益が含まれ、自己の財産権への侵害に対して相手の身体の安全を侵害する反撃行為に及んでも正当防衛となり得るかが問題となる。判例は、共有持分権等を有する被告人による増改築工事を妨害するため、被害者が「建築禁止」と記載した看板を建物に設置する行為を防止するために行われた暴行について、被害者の行為は財産権・業務・名誉に対する急迫不正の侵害であるから正当防衛により被告人の暴行罪の違法性が阻却されるとしている。

5 正しい

最判昭 44.12.4。本記述では、反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益よりも大であっても、その反撃行為が防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為は正当防衛となるかが問題となる。判例は、左手の中指と薬指をつかんで逆にねじあげられたのに対して、胸の辺りを1回強く突き飛ばし、治療45日を要する頭部打撲症の傷害を負わせたという事案において、36条1項の「やむを得ずにした行為」とは、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味するのであつて、反撃行為が右の限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益よりも大であつても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではないと解すべきである」とする。